

1502374-76.2020.8.26.0530

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Magistrado: Angel Tomas Castroviejo

Comarca: Sertãozinho

Foro: Foro de Sertãozinho

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 17/02/2022

... de entorpecentes e dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Apurou-se também que a após a prisão de João, vulgo "João Cara de Pizza", preso recentemente pelo crime de tráfico de drogas, seu irmão o acusado José, vulgo "Juninho", que saiu recentemente da prisão, assumiu a responsabilidade e gerência do tráfico de drogas que ocorre no local. Além disso, segundo apontou ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Sertãozinho

Foro de Sertãozinho

1ª Vara Criminal

Avenida Pedro Strini, 71, Sertãozinho-SP - cep 14160-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

1502374-76.2020.8.26.0530 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1502374-76.2020.8.26.0530

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante - 2275306/2020 - DEL.POL.BARRINHA

Autor:

Justiça Pública

Réu e Averiguado:

JOSE APARECIDO BALLERA JUNIOR e outros

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Angel Tomas Castroviejo

Vistos.

JOSÉ APARECIDO BALLERA JUNIOR e JAQUELINE CRISTINA GARCIA BALLERA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, c.c. art. 61, II, alínea "j", na forma do art. 69, ambos do Código Penal, porque, no dia 06 de novembro de 2020, por volta das 07h00, na Avenida Presidente Kenedy nº 1548, Centro, cidade de Barrinha, nesta comarca de

Sertãozinho, tinham em depósito, para fins de mercancia e entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 03 porções contendo o peso bruto de 327g (trezentos e vinte e sete gramas) de cocaína, substância entorpecente e que causa dependência física e psíquica.

Consta ainda que, no mesmo dia, por volta das 07h00, na cidade de Barrinha, nesta comarca de Sertãozinho, JOSÉ APARECIDO BALLERA JUNIOR, vulgo "Juninho", trazia consigo, para fins de mercancia e entrega de qualquer forma a consumo de terceiros, sem autorização e em desacordo com a determinação legal e regulamentar, 02 porções na forma de tabletes, com o peso bruto de 6,5g (seis gramas e cinco decigramas) da maconha, substância que causa dependência física e psíquica.

Consta, por fim, que a partir de data indeterminada, na Avenida Presidente Kenedy nº 1548, Centro, e na Rua Dom Pedro II, nº 657, cidade de Barrinha, nesta Comarca de Sertãozinho, JOSÉ APARECIDO BALLERA JUNIOR e JAQUELINE CRISTINA GARCIA BALLERA, associaram-se com o fim de praticarem, reiteradamente, o tráfico de entorpecentes. Segundo a denúncia, chegou ao conhecimento de policiais civis que no imóvel situado na Avenida Presidente Kenedy nº 1548, Barrinha, estava sendo guardado entorpecente, bem como dinheiro fruto do tráfico de drogas, uma vez que, após a prisão de seu irmão, conhecido por "João Cara de Pizza", o acusado José Aparecido assumiu a "gerência" do tráfico de entorpecentes que era levado a efeito pelo primeiro e a guarda do dinheiro que era produto da mercancia ilícita. Durante as investigações, policiais também apuraram que Jaqueline, irmã do acusado, era responsável pela contabilidade do tráfico e pela guarda do valor de origem criminoso, bem como que José Aparecido adotou o mesmo modo de execução do comércio de entorpecentes que era feito pelo irmão, recebendo a droga na casa, onde há monitoramento por câmeras de segurança, e armazenando, no referido imóvel, grandes porções de estupefacientes, que eram destinadas a abastecer "biqueiras". Todo o dinheiro arrecadado com o tráfico era levado para a casa de Jaqueline. A Autoridade Policial, diante das informações contidas em relatório de investigações, que dava conta que, além de José Aparecido, também Jaqueline estava comercializando drogas juntamente com o irmão no endereço supracitado, e outras amealhadas no transcurso do trabalho dos policiais civis, representou pela expedição de mandados de busca e apreensão para três endereços relacionados à atividade ilícita dos acusados, o que foi deferido nos Autos 1502674-31.2020.8.26.0597, tendo sido, então, organizada operação para o cumprimento da ordem judicial. Consta ainda na denúncia que na casa situada no local dos fatos, foram encontradas três porções grandes de cocaína, as quais ainda seriam fracionadas e embaladas para venda no varejo, além do valor de R\$ 1.741,30 (um mil, setecentos e quarenta e um reais e trinta centavos) e 50 saquinhos para embalagem de drogas. A casa, segundo as investigações, era utilizada pelos acusados para o tráfico de drogas, notadamente para armazenamento dos entorpecentes. No imóvel, foi apreendido um DVR com imagens gravadas. José Aparecido ali não estava no momento da diligência, mas foi encontrado em outro local, onde estava morando. O acusado, durante a abordagem policial, mostrou nervosismo e comportamento suspeito, com certo volume no bolso de sua bermuda, sendo que foi submetido a revista pessoal, encontrando-se em seu poder duas porções de "maconha", em tabletes, e o valor de R\$ 45,00 (quarenta e cinco reais), em notas trocadas. O acusado procurou fugir, mas não obteve êxito, tendo sido preso em flagrante. No outro endereço para o qual foi expedido o competente mandado de busca, na Rua Dom Pedro II nº 657, local onde Jaqueline declarou residir, foram encontrados oito aparelhos de telefone celular, dois deles na posse da acusada e outros seis dentro da residência diligenciada. Os aparelhos de telefone celular estão relacionados com a traficância de drogas. A acusada também foi presa em flagrante.

A denúncia foi recebida em 15 de dezembro de 2020 (fls. 321/322), os réus foram citados (Jaqueline - fls. 347; José - fls. 352) e apresentaram resposta à acusação (Jaqueline - fls. 416/418; José - fls. 409/411).

Durante a instrução foram colhidas as declarações de quatro testemunhas comuns da acusação e da defesa de José Aparecido, de três testemunhas arroladas pela defesa de Jaqueline, sendo os réus interrogados ao final.

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pugnou pela condenação

dos acusados, nos termos da denúncia (fls. 512/525)

A Defesa do acusado José requereu, no que tange ao delito do artigo 33, caput, da Lei 11.343/2006, a aplicação de pena mínima, além do reconhecimento da atenuante da confissão. Quanto ao crime do artigo 35, caput, do mesmo dispositivo de lei, a Defesa requereu a absolvição por falta de provas, e subsidiariamente, requereu a aplicação de penas mínimas, o reconhecimento da atenuante da confissão, além da detração pelo tempo que o réu ficou preso. Por fim, pleiteou a aplicação do regime prisional menos severo (fls. 547/554).

A Defesa da acusada Jaqueline pediu que seja reconhecida a ilegalidade da busca e apreensão no que tange aos smartphones, às câmeras de segurança e ao dispositivo de armazenamento de imagens, bem como a ilicitude das provas desta derivada, bem como o consequente desentranhamento do relatório de fls. 338 a 342, fruto de prova ilícita, e a desconsideração de todo trecho de testemunho que faça referência a tais provas. Em seguida, pleiteou a absolvição da ré por falta de provas.

Alternativamente, em cenário de condenação, requereu o afastamento da agravante genérica, a aplicação da minorante do artigo 33, §4º, da Lei n.º 11.343/06 em patamar máximo, além de concessão à ré para que recorra em liberdade (fls. 555/569).

É o relatório.

DECIDO.

Primeiramente, de rigor o afastamento da preliminar arguida pela defesa da ré Jaqueline quanto à ilegalidade das provas obtidas por ocasião do cumprimento do mandado de busca e apreensão.

Diversamente do que sustentou a Defesa, a ordem concedida para busca e apreensão teve por objetivo localizar a apreender tudo que fosse necessário a auxiliar e instruir as investigações prezando sempre pela busca da verdade real, inclusive aparelhos eletrônicos que poderiam conter informações importantes para o deslinde das investigações.

Pontue-se, por oportuno, que a apreensão de celulares, câmeras de segurança e quejandos, bem como sua devassa, é decorrência lógica da medida cautelar de busca e apreensão devidamente executada. Os referidos objetos e a análise de seus conteúdos, estão dentro do desdobramento fático necessário da medida, sendo ações imprescindíveis para à conclusão das investigações, com lastro em diligências anteriores que serviram de suporte fático e fundamento para a decretação da medida. Desta forma, a ilegalidade ou nulidade apontada pela Douta Defesa não possui consistência jurídica, já que em razão da autorização judicial não houve mácula ao sigilo do conteúdo dos objetos apreendidos.

Neste sentido já se pronunciou o Supremo Tribunal Federal e o Superior Tribunal de Justiça:

"PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ORDINÁRIO EM HABEAS CORPUS.

ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. CONCUSSÃO. CORRUPÇÃO PASSIVA. DEVASSA DE DADOS DE APARELHO CELULAR. LEGALIDADE. APARELHO APREENDIDO EM CUMPRIMENTO DE MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO. 1. São lícitas as provas obtidas de aparelhos celulares quando recolhidos em cumprimento de mandado de busca e apreensão, independente de autorização posterior para acesso aos seus dados, por ser o objetivo final do instituto. 2. Na mesma linha a manifestação da Procuradoria-Geral da República, para quem "os telefones celulares foram apreendidos em cumprimento ao mandado de busca e apreensão. Assim, não há ilegalidade a ser reparada". 3. Agravo regimental desprovido, na linha do parecer ministerial. (AgRg no RHC 125.734/SP, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 23/11/2021, DJe 26/11/2021)

"HABEAS CORPUS. NULIDADES: (1) INÉPCIA DA DENÚNCIA; (2) ILICITUDE DA PROVA PRODUZIDA DURANTE O INQUÉRITO POLICIAL; VIOLAÇÃO DE REGISTROS TELEFÔNICOS DO CORRÉU, EXECUTOR DO CRIME, SEM AUTORIZAÇÃO JUDICIAL; (3) ILICITUDE DA PROVA DAS INTERCEPTAÇÕES TELEFÔNICAS DE CONVERSAS DOS ACUSADOS COM ADVOGADOS, PORQUANTO ESSAS GRAVAÇÕES OFENDERIAM O DISPOSTO NO ART. 7º, II, DA LEI 8.906/96, QUE GARANTE O SIGILO DESSAS CONVERSAS. VÍCIOS NÃO CARACTERIZADOS. ORDEM DENEGADA. 1. Inépcia da denúncia. Improcedência. Preenchimento dos requisitos do art. 41 do CPP. A denúncia narra, de forma pormenorizada, os fatos e as circunstâncias. Pretensas omissões -

nomes completos de outras vítimas, relacionadas a fatos que não constituem objeto da imputação -- não importam em prejuízo à defesa. 2. Ilicitude da prova produzida durante o inquérito policial - violação de registros telefônicos de corrêu, executor do crime, sem autorização judicial. 2.1 Suposta ilegalidade decorrente do fato de os policiais, após a prisão em flagrante do corrêu, terem realizado a análise dos últimos registros telefônicos dos dois aparelhos celulares apreendidos. Não ocorrência. 2.2 Não se confundem comunicação telefônica e registros telefônicos, que recebem, inclusive, proteção jurídica distinta. Não se pode interpretar a cláusula do artigo 5º, XII, da CF, no sentido de proteção aos dados enquanto registro, depósito registral. A proteção constitucional é da comunicação de dados e não dos dados. 2.3 Art. 6º do CPP: dever da autoridade policial de proceder à coleta do material comprobatório da prática da infração penal. Ao proceder à pesquisa na agenda eletrônica dos aparelhos devidamente apreendidos, meio material indireto de prova, a autoridade policial, cumprindo o seu mister, buscou, unicamente, colher elementos de informação hábeis a esclarecer a autoria e a materialidade do delito (dessa análise logrou encontrar ligações entre o executor do homicídio e o ora paciente). Verificação que permitiu a orientação inicial da linha investigatória a ser adotada, bem como possibilitou concluir que os aparelhos seriam relevantes para a investigação. 2.4 À guisa de mera argumentação, mesmo que se pudesse reputar a prova produzida como ilícita e as demais, ilícitas por derivação, nos termos da teoria dos frutos da árvore venenosa (fruit of the poisonous tree), é certo que, ainda assim, melhor sorte não assistiria à defesa. É que, na hipótese, não há que se falar em prova ilícita por derivação. Nos termos da teoria da descoberta inevitável, construída pela Suprema Corte norte-americana no caso Nix x Williams (1984), o curso normal das investigações conduziria a elementos informativos que vinculariam os pacientes ao fato investigado. Bases desse entendimento que parecem ter encontrado guarida no ordenamento jurídico pátrio com o advento da Lei 11.690/2008, que deu nova redação ao art. 157 do CPP, em especial o seu § 2º. 3. Ilicitude da prova das interceptações telefônicas de conversas dos acusados com advogados, ao argumento de que essas gravações ofenderiam o disposto no art. 7º, II, da Lei n. 8.906/96, que garante o sigilo dessas conversas. 3.1 Nos termos do art. 7º, II, da Lei 8.906/94, o Estatuto da Advocacia garante ao advogado a inviolabilidade de seu escritório ou local de trabalho, bem como de seus instrumentos de trabalho, de sua correspondência escrita, eletrônica, telefônica e telemática, desde que relativas ao exercício da advocacia. 3.2 Na hipótese, o magistrado de primeiro grau, por reputar necessária a realização da prova, determinou, de forma fundamentada, a interceptação telefônica direcionada às pessoas investigadas, não tendo, em momento algum, ordenado a devassa das linhas telefônicas dos advogados dos pacientes. Mitigação que pode, eventualmente, burlar a proteção jurídica. 3.3 Sucede que, no curso da execução da medida, os diálogos travados entre o paciente e o advogado do corrêu acabaram, de maneira automática, interceptados, aliás, como qualquer outra conversa direcionada ao ramal do paciente. Inexistência, no caso, de relação jurídica cliente-advogado. 3.4 Não cabe aos policiais executores da medida proceder a uma espécie de filtragem das escutas interceptadas. A impossibilidade desse filtro atua, inclusive, como verdadeira garantia ao cidadão, porquanto retira da esfera de arbítrio da polícia escolher o que é ou não conveniente ser interceptado e gravado. Valoração, e eventual exclusão, que cabe ao magistrado a quem a prova é dirigida. 4. Ordem denegada." (HC 91867, Relator(a): GILMAR MENDES, Segunda Turma, julgado em 24/04/2012, ACÓRDÃO ELETRÔNICO DJe-185 DIVULG 19-09-2012 PUBLIC 20-09-2012)

"PROCESSUAL PENAL. OPERAÇÃO "LAVA-JATO". MANDADO DE BUSCA E APREENSÃO. APREENSÃO DE APARELHOS DE TELEFONE CELULAR. LEI 9296/96. OFENSA AO ART. 5º, XII, DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL. INOCORRÊNCIA. DECISÃO FUNDAMENTADA QUE NÃO SE SUBORDINA AOS DITAMES DA LEI 9296/96. ACESSO AO CONTEÚDO DE MENSAGENS ARQUIVADAS NO APARELHO. POSSIBILIDADE. LICITUDE DA PROVA. RECURSO DESPROVIDO. I - A obtenção do conteúdo de conversas e mensagens armazenadas em aparelho de telefone celular ou smartphones não se subordina aos ditames da Lei 9296/96. II - O acesso ao conteúdo armazenado em telefone celular ou smartphone, quando determinada judicialmente a busca e apreensão destes aparelhos, não ofende o art. 5º, inciso XII, da Constituição da

República, porquanto o sigilo a que se refere o aludido preceito constitucional é em relação à interceptação telefônica ou telemática propriamente dita, ou seja, é da comunicação de dados, e não dos dados em si mesmos. III - Não há nulidade quando a decisão que determina a busca e apreensão está suficientemente fundamentada, como ocorre na espécie. IV - Na pressuposição da ordem de apreensão de aparelho celular ou smartphone está o acesso aos dados que neles estejam armazenados, sob pena de a busca e apreensão resultar em medida irrita, dado que o aparelho desprovido de conteúdo simplesmente não ostenta virtualidade de ser utilizado como prova criminal. V - Hipótese em que, demais disso, a decisão judicial expressamente determinou o acesso aos dados armazenados nos aparelhos eventualmente apreendidos, robustecendo o alvitre quanto à licitude da prova. Recurso desprovido." (RHC 75.800/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 15/09/2016, DJe 26/09/2016)

Assim, não havendo nulidade a ser sanada, fica afastada a preliminar suscitada, com manutenção das provas colhidas na fase investigativa e que servem de lastro para a peça acusatória.

No mais, a pretensão punitiva estatal é procedente em parte.

A materialidade dos delitos encontra-se comprovada pelo auto de prisão em flagrante (fls. 06), pelo boletim de ocorrência (fls. 14/18), pelo auto de exibição e apreensão (fls. 21/23), pelos laudos químico-toxicológicos (fls. 287/289 e 290/292), conclusivos por se tratar de cocaína, e pelos depoimentos colhidos durante a instrução.

A autoria também foi devidamente comprovada, apenas em relação ao réu José.

Os policiais civis Luiz Carlos e Aline, na fase policial, disseram que na data dos fatos foi dado cumprimento ao Mandado de Busca e Apreensão Criminal expedido no processo nº 1502674-31.2020.8.26.0597 da 1ª Vara Criminal de Sertãozinho. Para tanto, foi organizada operação policial, que contou com o apoio de policiais civis da área da Delegacia Seccional de Sertãozinho. A investigação apurou que no imóvel situado no endereço Av. Presidente Kennedy nº 1548 estava ocorrendo a guarda de entorpecentes e dinheiro oriundo do tráfico de drogas. Apurou-se também que a após a prisão de João, vulgo "João Cara de Pizza", preso recentemente pelo crime de tráfico de drogas, seu irmão o acusado José, vulgo "Juninho", que saiu recentemente da prisão, assumiu a responsabilidade e gerência do tráfico de drogas que ocorre no local. Além disso, segundo apontou a investigação, Jaqueline e a mãe Tereza são as responsáveis pela contabilidade do tráfico e guarda do dinheiro proveniente da venda de drogas, sendo que, segundo se apurou, o acusado manteve o modus operandi de seu irmão "João", o qual recebe a droga na casa, onde inclusive há monitoramento por câmeras de segurança, as quais são guardadas ainda em grandes porções em um "buraco" próximo do telhado. Para isso eram utilizadas linhas de pesca e sacos plásticos, pois as drogas eram embaladas e amarradas em sacos plásticos e colocadas dentro do "buraco" entre as telhas do telhado. Assim, quando era necessário fracionar mais drogas (cocaína) bastava puxar as linhas, e retirar a quantidade de droga necessária para se abastecer os pontos de venda "biqueiras". A investigação também apurou que todo dinheiro arrecadado era levado para a casa de Jaqueline, ainda no período da manhã, para sua residência, situada na Rua Dom Pedro II nº 657. Através da investigação e de informações privilegiadas obtidas com pessoas as quais preferem não se identificar, foi possível encontrar o tal "buraco". Com todas as informações reunidas, foi feito o pedido de busca e após autorizado, deflagrou-se operação policial, que confirmou todas as informações e modus operandi dos acusados. Na casa situada na Av. Presidente Kennedy nº 1548, foram localizadas três porções grandes de cocaína, as quais ainda seriam fracionadas e embaladas para venda no varejo, além de R\$ 1.741,30 e saquinhos para embalagem das drogas. Na casa situada na Rua Dom Pedro II nº 657, foram localizados um total de oito aparelhos celulares, sendo que dois deles estavam em posse da acusada Jaqueline e outros seis aparelhos guardados em sua casa. Na casa situada na Rua Toshimito Sobue nº 541, casa A, não foi realizada a busca, pois, lá chegando, apurou-se que havia outros moradores no local, diversos dos apontados na investigação e que não guardavam relação com os acusados. Durante as buscas, "Juninho" não foi localizado no imóvel

onde mantém as drogas guardadas, pois o local já é muito conhecido pelos policiais desta cidade, porém, identificado o local onde "Juninho" estava morando, para lá se dirigiram os policiais, que fizeram contato com o acusado e este franqueou a entrada em sua residência, pois alegava que ali não haveria nada de ilícito. Contudo, os policiais notaram que "Juninho" estava muito preocupado e com certo volume no bolso de sua bermuda. Foi então realizada revista pessoal, e localizada duas porções de maconha, ainda em tabletes, e R\$ 45,00 em notas trocadas. Neste momento, "Juninho" tentou se evadir do local, ao sair correndo pela rua, sem sucesso, pois logo foi alcançado e algemado, já que ainda tentou resistir a sua prisão (fls. 07/08 e 09/10).

Em Juízo, a testemunha Luís Carlos disse que só participou das diligências visando o cumprimento do mandado de busca e apreensão. A investigadora Cláudia foi quem comandou a investigação. Afirmou que foi o responsável pela diligência do imóvel da rua Toshimito Sobue. No imóvel do endereço na Avenida Presidente Kennedy nº 1548. A testemunha reportou que já sabiam do local específico onde estava a droga, no telhado, dentro do imóvel, porém não foi responsável por diligências neste endereço. Aduziu que Juninho negou a existência de objetos ilícitos na casa e, durante a diligência, tentou fugir. Os réus foram uníssonos em asseverar que o local era usado pelo irmão, o qual estava preso, com negativa sobre a autoria do delito. Disseram, ainda, que os entorpecentes não estavam fracionados (v. mídia). Em Juízo, a testemunha Aline disse que participou apenas do cumprimento de mandato, não chegando a ter contato com a ré Jaqueline ou com qualquer outro abordado. Disse que no imóvel localizado na Rua Dom Pedro II nº 657, endereço de Jaqueline, havia celulares, mas não havia drogas. Aduziu ter sido responsável pelo relatório das imagens, nas quais verificou que Jaqueline e Teresa transitavam constantemente pelo local, portando com sacolas, sendo que o réu passava coisas por um buraco existente no muro. Por fim, informou que nas imagens foi possível ver Luciano fazendo a venda da drogas (v. mídia).

A policial civil Cláudia, nos autos de nº 1502674-31.2020, emitiu relatório, no qual constou a existência de denúncia anônima sobre o exercício de mercancia de drogas no endereço localizado na Avenida Presidente Kennedy nº 1526/1548, local poderiam ser encontrados os acusados e outras pessoas consumindo entorpecentes (cocaína e crack). Segundo o relatório, as drogas são escondidas dentro da residência nº 1548. Há possibilidade de fuga e olheiros, os quais possuem arma de fogo. Dois dos três acusados possuem passagem por tráfico de drogas e já foram presos pelo mesmo crime. O local é conhecido como ponto de venda de entorpecentes e, após pesquisa no sistema Detecta, verificou-se algumas denúncias de drogas envolvendo o numeral 1526 e 1548. Em diligências no endereço, constataram que foram instalados recentemente câmeras de monitoramento em torno da residência e, em conversa com populares, foram informados que Jaqueline reside em outro imóvel, localizado na Rua Toshimito Sobue nº 541, casa A, no bairro Vila Recreio, e que lá também há entorpecentes escondidos, pois o local da denúncia é muito visado pelos policiais da cidade. Soube-se também que Teresa alugou recentemente um imóvel localizado na Rua Dom Pedro II nº 657, o qual é usado para guarda e embalagem do entorpecente. Em pesquisa, verificaram que Teresa e Juninho são mãe e filho, os quais foram presos pelo crime de tráfico de drogas, conforme RDO 612/2015, sendo a única ocorrência de Teresa. Já Juninho ostenta passagens anteriores por tráfico, de acordo com RDO 1059/2013 e 328/2013. A acusada Jaqueline, filha de Teresa, não tem passagens, porém seu marido está preso após ser apreendido com entorpecente, conforme RDO 348/2018, com passagem anterior também por tráfico de drogas, de acordo com RDO 688/2017 (fls. 03/06 dos autos de nº 1502674-31.2020).

Em Juízo, Cláudia disse que as investigações foram impulsionadas por uma denúncia anônima referente ao endereço da Pr. Kennedy. Quanto ao modus operandi informado, relatou que os réus recebiam a droga e escondiam no telhado com fita de nylon, sendo que os envolvidos eram Juninho, a mãe, responsável pelo transporte do dinheiro para a acusada Jaqueline toda manhã, cabendo a ambas a guarda das quantias arrecadadas. Disse, outrossim, que o endereço da Pr. Kennedy era habitado. Ao final, salientou que a droga estava fracionada (v. mídia).

A testemunha policial civil Edmar, nos autos de nº 1502674-31.2020, disse que há

tempos a polícia vem investigando os acusados João e "Juninho" pelos crimes de tráfico de drogas e associação para o tráfico, tendo eles inclusive já sido presos pelo primeiro delito. Por várias vezes foram representados e cumpridos mandados de busca nos imóveis locais dos fatos, que são contíguos, pois há um portão de acesso entre eles. Em todas as vezes, a acusada Teresa, mãe deles, estava no imóvel e afirmava ter ciência de que seus filhos faziam ali tráfico de drogas, porém, alegava que lhes "dava conselhos", mas não adiantava. Na data dos fatos, deslocaram-se até as residências situadas nos locais dos fatos a fim de cumprir Mandado de Busca e Apreensão expedido pelo Juízo da 1ª Vara Criminal de Sertãozinho, processo n. 0003017-77.2015.8.26.0597, onde vieram a localizar e apreender os objetos, valores e drogas ora relacionadas. Antes, porém, da abordagem e entrada no imóvel local dos fatos, o depoente pôs-se de "campana", numa viatura descaracterizada, a uma distância razoável do local, de onde pode observar os acusados João e Lennon venderem drogas na rua, bem próximo à casa onde moram João e Teresa, bem como pode ver João entrando e saindo de sua casa após receber algo, possivelmente o dinheiro, ora diretamente de usuários, ora de Lennon, que intermediava o comércio, concluindo-se que fora buscar as porções de droga comercializadas. Pode ver também o acusado Lennon ir até o terreno baldio, situado na mesma rua, local este onde foram encontradas drogas e cápsulas vazias. Diante de tais fatos, na certeza de que os acusados estavam vendendo drogas, desencadeou-se a ação policial, ocasião em que os acusados foram abordados, sendo encontradas com eles quantias (com João R\$260,00 e com Lennon R\$231,00) em notas diversas. Logo na entrada da casa de João, imóvel este que pertence a sua mãe, a ora acusada, foram encontradas as porções de cocaína e "crack", junto a um vaso. Na caixa do correio, foram encontrados R\$3,40 em moedas. Como de costume, visto que a Autoridade subscritora já cumpriu vários mandados de busca no local, a acusada encontrava-se no interior da casa e, por óbvio, tinha plena ciência de que o imóvel estava sendo usado por seus filhos para o tráfico de drogas. O acusado José Aparecido Ballera Junior, "Juninho", irmão de João e filho de Teresa, mora num cômodo nos fundos do imóvel ao lado, o de n. 1526, sendo que há um portão de acesso nos fundos da casa da acusada, que liga os dois imóveis. "Juninho" não se encontrava no local no momento da abordagem policial. No cômodo onde mora "Juninho", o investigador LISI localizou, sob um guarda-roupas, um buraco no chão, coberto por um piso, ou seja, um "fundo falso", onde foi encontrado o "tijolo" de "maconha" de 350 gramas. Importante consignar que próximo ao local dos fatos (cerca de duas ou três quadras) existem três escolas de educação infantil, quais sejam: EMEF Dr. Angelo Carlos Jordão (R. Gal. Osório 155), EMEF Prof. Darvy Mascaro (R. Sussumo Okano, 460) e Colégio Flamboyant (R. Sussumo Okano, 309) (fls. 21/22 dos autos de nº 1502674-31.2020).

A testemunha Elenice, arrolada pela Defesa de José, é amiga da família e vizinha dos réus, durante o tempo que residia na av. Presidente Kennedy. Na data dos fatos a mãe dos réus residia com Jaqueline porque estava doente. Não via movimentação típica de "biqueira" na casa do réu. O réu morava a cerca de 05 quarteirões de distância e o local de residência do irmão preso estava desabitado (v. mídia). A testemunha Kelli, arrolada pela Defesa de José, disse que é conhecida dos réus. Mora próximo da casa onde a Tereza morava, antes de Teresa ir morar com a filha. Quanto ao endereço da Pr. Kennedy, disse que sempre passava pelo local e nunca viu movimentação suspeita. Disse também que no local deixado por Teresa não mora ninguém (v. mídia).

A testemunha Sulamita, arrolada pela Defesa de Jaqueline, disse que trabalha com a ré faz cerca de 15 anos, no pronto socorro de Barrinha. Disse que sabia que com Jaqueline morava a mãe, o filho e o sobrinho. Disse que a ré usava o cartão de crédito da declarante e sempre pagou o que comprava, inclusive os celulares que eram todos para uso próprio (v. mídia).

A testemunha Carla, arrolada pela Defesa de Jaqueline, disse que fez curso de enfermagem com a ré. Assentou que Jaqueline era assídua no curso e não costumava faltar (v. mídia).

A testemunha Luziana, arrolada pela Defesa de Jaqueline, disse que é vizinha da acusada e estava na oficina do marido quando os policiais estiveram na casa de

Jaqueline. Pelo que apurou, para ter acesso à casa de Jaqueline os policiais arrombaram o portão da depoente e pularam o muro para entrar na casa de Jaqueline. Disse que no imóvel moravam Jaqueline, mãe e filho (v. mídia). A ré Jaqueline, quando interrogada na fase policial, negou ter envolvimento com o tráfico de drogas, alegou que os aparelhos celulares são de sua propriedade e que não os recebeu como pagamento de drogas, nem tampouco é usado para despistar a polícia em um futuro grampo telefônico. Os aparelhos foram comprados por terceiros para a interroganda, pois tem o nome sujo no comércio, o que impede de comprar a crédito. Informa que os aparelhos, um deles não funciona com wifi, por isso comprou outro. Um dos aparelhos é de seu irmão João, que está preso, o qual foi deixado na responsabilidade da interroganda, outro é de sua irmã Carolina, que deixou para uso da mãe, outro é do sobrinho Thiago, que mora na residência, e está com a tela danificada. A casa onde a droga foi encontrada era a residência de seu irmão João, e ali ficaram apenas os cachorros, sendo que a interroganda apenas vai lá para alimentar os animais. A interroganda reside com sua mãe, um seu filho e um sobrinho, trabalha no período noturno em hospital onde é concursada, já durante o dia frequenta escola técnica em Jaboticabal, voltando para casa somente à noite. Deixou quatro notas fiscais dos aparelhos celulares encontrados em sua casa, sendo que não tem a nota dos outros aparelhos celulares, por pertencerem a terceiros ou serem muito antigos (fls. 13). Em Juízo, disse que nunca vendeu droga e que sempre trabalhou e estudou. Aduziu que trabalha cerca de 120 horas por mês e constantemente faz horas extras, além de estudar das 08:00 às 12:00. Quanto ao imóvel onde foram encontrados os ilícitos, disse que na av. Presidente Kennedy moravam João e Teresa. Disse que ia no imóvel para tratar dos cachorros e limpar a residência uma vez por semana. Informou que não tinha muita convivência com o corréu e sabe apenas que ele é usuário de Maconha. Quanto aos celulares encontrados, disse que 04 são da interroganda e outros 04 não são, sendo que 01 celular era do irmão João, 01 era de Teresa, 01 outra irmã e 01 quebrado do sobrinho. Apontou ainda que genitora Teresa ia no imóvel quando a interroganda não podia ir (v. mídia).

O réu José, quando interrogado na fase policial, negou praticar tráfico de drogas, pois saiu recentemente da cadeia e não mais quer envolvimento com o crime. É viciado em maconha. Na manhã dos fatos, estava em sua residência e se preparava para sair para recolher recicláveis, que é seu meio de sustento, e ali chegou a polícia, informando sobre o mandado de busca, então autorizou aos policiais a entrada na casa e nada de irregular foi encontrado. Contudo, no bolso do interrogando foi encontrado duas trouxinhas de maconha, que o interrogando havia comprado no dia anterior em uma biqueira e que havia dividido a compra em duas porções, sendo que uma seria consumida durante o trabalho e a outra a noite. Sabe que sua irmã Jaqueline reside com a genitora, o filho do interrogando e um filho dela, mas nega que Jaqueline seja traficante, pois ela trabalha o dia todo no hospital de Barrinha, portanto, não tem tempo para outras coisas (fls. 11/12). Em Juízo, admitiu que guardava a droga para terceira pessoa, por dificuldade financeira advinda com a pandemia. Fazia cerca de 02 meses que guardava a droga e recebia cerca de R\$ 500,00 (quinhentos reais) por semana. Disse que não vendia a droga, apenas guardava. Disse que a esposa não sabia do acontecimento e que Jaqueline ia esporadicamente ao local e não sabia que guardava a droga. Disse ainda que está arrependido dos atos (v. mídia).

Por sua vez, conforme dispõe o art. 52, inciso I, da Lei 11.343/06, deve-se levar em consideração, para classificação do delito, a natureza e a quantidade da substância apreendida, bem como as circunstâncias da prisão.

Diante das provas produzidas durante a instrução, é possível concluir que o réu José Aparecido era realmente o proprietário das drogas apreendidas e que se destinariam à comercialização.

Conforme narrado de forma uníssona pelas testemunhas policiais civis, há tempos receberam denúncia anônima no sentido de que os réus, sua genitora e seu irmão João estavam traficando drogas. Em operação policial, apuraram que no imóvel situado no endereço Av. Presidente Kennedy nº 1548 armazenamento de entorpecentes e dinheiro oriundo do tráfico de drogas, bem como que após a prisão de João, vulgo "João Cara

de Pizza", preso recentemente pelo crime de tráfico de drogas, seu irmão, o acusado José, vulgo "Juninho", que saiu recentemente da prisão, assumiu a responsabilidade e gerência do tráfico de drogas que ocorre no local.

Na casa situada na Av. Presidente Kennedy nº 1548, foram localizadas três porções grandes de cocaína, as quais ainda seriam fracionadas e embaladas para venda no varejo, além de R\$ 1.741,30 e saquinhos para embalagem das drogas, como bem atestam o auto de exibição e apreensão (fls. 21/23) e os laudos químico-toxicológicos (fls. 287/289 e 290/292)

Durante as buscas, diligenciaram até a residência de "Juninho", e em revista pessoal foram localizadas duas porções de maconha, ainda em tabletes, e R\$ 45,00 em notas trocadas. "Juninho" tentou se evadir do local, ao sair correndo pela rua, sem sucesso, pois logo foi alcançado e algemado.

Ademais, o próprio réu confessou que guardava a droga para terceiro desconhecido, recebendo uma quantia de R\$500,00 pelo serviço.

Deste modo considerando que os policiais confirmaram com bastante segurança que as investigações apontam José como responsável por guardar e traficar drogas, bem como porque encontrado em sua posse porções destinadas ao comércio, e que ele próprio chegou a confessar o delito em Juízo, conclui-se que o réu José efetivamente traficava na ocasião.

Observe-se que a credibilidade dos depoimentos dos policiais ainda vem corroborada pela prova documental e pericial já citadas, sendo certo que não existe qualquer indicativo nos autos de que tivessem a intenção de prejudicar os acusados.

Ademais, "o valor de depoimento testemunhal de servidores policiais - especialmente quando prestados em juízo, sob a garantia do contraditório - reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-lo pelo só fato de emanar de agentes estatais incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal. O depoimento testemunhal do agente policial somente não terá valor quando se evidenciar que esse servidor do Estado, por revelar interesse particular na investigação penal, age facciosamente ou quando demonstrar - tal como ocorre com as demais testemunhas - que as suas declarações não encontram suporte e nem se harmonizam com os outros elementos probatórios idôneos." (STF - HC nº 73.518-5 - Rel. Min. Celso de Mello, DJU 18.10.96, p. 39.846).

Em relação à denunciada Jaqueline, não há elementos probatórios suficientes para um decreto condenatório.

Pelas provas colhidas durante a fase investigativa e durante a instrução processual, observa-se que na casa situada na Rua Dom Pedro II nº 657, foram localizados um total de oito aparelhos celulares. Dois deles estavam em posse da acusada Jaqueline, já outros seis aparelhos estavam guardados em sua casa. Durante as diligências efetuadas em cumprimento do mandado de busca e apreensão, os policiais civis não flagraram a ré vendendo drogas para qualquer pessoa, ou demais informes sobre a prática de atividade de mercancia de substâncias ilícitas imputáveis à denunciada.

O elo entre a conduta da acusada e a descrição típica feita na denúncia está consubstanciada na apreensão de aparelhos celulares na residência onde mora e no fato da denunciada frequentar, de forma constante, juntamente com sua genitora, o local onde as drogas foram apreendidas. Referido cabedal fático é insuficiente para cravar a autoria delitiva, já que pelo desenvolvimento da marcha processual não houve êxito em transformar os indícios, balizadores do recebimento da denúncia, em provas concretas e seguras para a condenação.

A ré Jaqueline, por sua vez, negou a propriedade da droga apreendida, alegando que os aparelhos celulares são de sua propriedade e que não os recebeu como pagamento de drogas e nem tampouco são usados para despistar a polícia em um futuro grampo telefônico. Ainda, alegou que a casa onde a droga foi encontrada era a residência de seu irmão João, e ali ficaram apenas os cachorros, sendo que a acusada apenas vai lá para alimentar os animais. Por fim, disse que trabalha no período noturno em hospital onde é concursada e durante o dia frequenta escola técnica em Jaboticabal, voltando para casa somente à noite, depoimento este corroborado pelas testemunhas Sulamita e Carla.

Não obstante a firme argumentação acusatória, mormente em sede de alegações finais,

a apreensão de celulares, a visitação do imóvel onde as drogas foram apreendidas, o qual já serviu de moradia de seu irmão, bem como o fato de acusada não possuir notas fiscais dos aparelhos em seu nome, são alegações contraditadas durante o interrogatório, com arrimo em depoimento testemunhal, gerando dúvida razoável sobre o envolvimento da denunciada no exercício do comércio de entorpecentes, esmaecendo a tese do órgão acusador.

Nesta senda, à míngua de outros elementos de prova, a alegação do órgão ministerial de que a compra de aparelhos celulares por terceira pessoa seria uma estratégia para esconder a atividade ilícita não pode ser considerada mais do que mera conjectura.

Diante da insuficiência de provas, igualmente não se pode concluir que os réus estivessem associados, de forma estável e permanente, para o tráfico de drogas. Demonstrada, pois, a materialidade e indubitosa a autoria, tem-se que é de rigor a condenação do réu José Aparecido como incurso no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, passando-se à dosimetria da pena.

Atento ao disposto nos artigos 59 e 60 do Código Penal e 42 e 43 da Lei 11.343/06, fixo a pena base do réu José 1/6 acima do mínimo legal, em 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e pagamento de 583 (quinhentos e oitenta e três) dias-multa, para o delito de tráfico, porque o réu é portador de maus antecedentes (v. certidão de fls. 499/502 – autos de nº 2177-38.2013).

Na segunda fase, observo que o réu José é confesso e reincidente específico (v. certidão de fls. 499/502 – autos de nº 3273-20.2015). Diante da preponderância da circunstância agravante da reincidência, que no caso ainda é específica, nos termos do art. 67 do Código Penal, as penas devem ser majoradas em 1/5, alcançando 07 (sete) anos de reclusão e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa.

Quanto à agravante sustentada pelo Ministério Público em alegações finais, prevista no art. 61, II, "j", do Código Penal, reputo que não incide no caso, por considerar que a pandemia do coronavírus não causou situação de calamidade pública, ainda que formalmente assim reconhecidas por decretos, mas apenas restrições do tráfego de parte da população, e impedimento, também somente em certo período, do exercício de algumas atividades profissionais. Também não há prova de que o delito teria sido cometido aproveitando-se o acusado da situação de pandemia, ou em razão dela, nem houve descoberta de elementos colhidos durante a instrução processual nesse sentido.

Na terceira fase, deixo de aplicar a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, § 4º, da Lei 11.343/06, porque reincidente o réu.

Não havendo outras circunstâncias agravantes ou atenuantes a considerar ou mesmo causas de aumento ou diminuição da pena, torno definitiva a pena fixada.

O valor do dia-multa é fixado no mínimo de 1/30 do maior salário mínimo vigente à época dos fatos, atualizado a partir da mesma data.

Ante o exposto, julgo PROCEDENTE EM PARTE a pretensão punitiva estatal para CONDENAR o réu JOSÉ APARECIDO BALLERA JUNIOR, qualificado nos autos, à pena 07 (sete) anos de reclusão, em regime inicial fechado, e pagamento de 699 (seiscentos e noventa e nove) dias-multa, no valor mínimo, como incurso no art. 33, caput, da Lei 11.343/06, e ABSOLVÊ-LO da prática do delito previsto no art. 35, caput, da Lei 11.343/06, bem como para ABSOLVER a ré JAQUELINE CRISTINA GARCIA BALLERA, qualificada nos autos, da prática dos delitos previstos no art. 33, caput, e 35, caput, ambos da Lei 11.343/06, com fundamento no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

Incabível a substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44 do Código Penal, bem como a suspensão condicional da pena, porque o réu é reincidente. O réu cumprirá a pena no regime inicial fechado e não poderá recorrer em liberdade, diante do reconhecimento da reincidência. Ademais, o réu permaneceu preso durante todo o processo, para garantia da ordem pública, foi condenado a elevada pena, praticou delito equiparado a hediondo, nada justificando a soltura após a condenação, ficando ratificados, ademais, os argumentos expostos na decisão de fls. 108/111.

Declaro a perda, em favor da União, do dinheiro apreendido, porque não comprovada

sua origem lícita, presumindo que fosse proveniente da atividade ilícita do tráfico.

Em relação aos aparelhos celulares apreendidos na residência da ré Jaqueline, defiro a restituição daqueles cuja propriedade foi comprovada, notadamente os que se referem à declaração de fl. 186 e nota fiscal de fl. 189, estando as demais notas fiscais (fls. 185, 186 e 188) em nome de terceiros, resta indeferida a restituição nos termos do art. 120, § 1º, do Código de Processo Penal.

Em face da condenação, o réu José arcará com o pagamento da taxa judiciária no valor de 100 (cem) UFESPs, nos termos do artigo 4º, § 9º, letra "a", da Lei Estadual 11608/03, ficando sobrestada a cobrança, caso seja beneficiário da assistência judiciária gratuita.

Diante do documento de fl. 174, defiro à ré Jaqueline a concessão dos benefícios da assistência judiciária gratuita. Anote-se.

Expeça-se ofício de recomendação em relação ao réu José.

P.R.I.C.

Sertãozinho, 17 de fevereiro de 2022.

Angel Tomas Castroviejo
Juiz de Direito

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA